

1011584-58.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Roberta Virginio dos Santos

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... por falta de comunicação imediata do furto sofrido ao Banco e por falta de diligência ao manter conjuntamente seu cartão e senha pessoal (artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Defende não ser caso de aplicação de inversão do ônus da prova e destaca que o Boletim de Ocorrência apresentado se trata de mera prova unilateral, sem parte no conjunto probatório dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Cível

Avenida Brasil Sul, n.º 2669, Americana - SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1011584-58.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011584-58.2021.8.26.0019

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Marley Luiza Succì dos Reis

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO

Em 15/12/2022, faço estes autos conclusos a MMª. Juíza de Direito Auxiliar em exercício na 2ª Vara Cível, Dra. Roberta Virginio dos Santos.

A Escte.

Juíza de Direito Auxiliar em exercício: Dra. Roberta Virginio dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada com Obrigação de Fazer proposta por MARLEY LUIZA SUCCI DOS REIS contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, já qualificados.

Narra a inicial, em síntese, que a autora possui a conta corrente nº 0360.01.035604-4, da agência 389, do Banco réu, esta utilizada para o recebimento de seu benefício previdenciário. Que no dia 29/09/2021, por volta das 13 horas e 30 minutos, a autora foi vítima de assalto por duas mulheres ao sair da agência bancária da instituição financeira ré. Realizou Boletim de Ocorrência e procedeu ao imediato bloqueio do cartão bancário. Ocorre que, no início do mês de outubro, a autora recebeu três cartas com informações relativas a realização de três

empréstimos consignados no dia 29/09/2021. Tentou resolver o impasse administrativamente, sem êxito. Após pesquisa, constatou que o primeiro empréstimo consignado foi realizado às 13 horas e 45 minutos, no valor de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), para pagamento em 37 parcelas no valor de R\$ 299,51 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), com início programado para o mês de novembro de 2021 e término previsto para outubro de 2024. O segundo empréstimo consignado foi realizado às 13 horas e 48 minutos, no valor de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para pagamento em 2 parcelas no valor de R\$ 366,75 (trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), com início em novembro de 2021. Por fim, o terceiro empréstimo consignado foi realizado às 13 horas e 48 minutos, no valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), para pagamento em 2 parcelas no valor de R\$ 372,71 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), com início em setembro de 2021. Além dos empréstimos citados foi efetuado o saque do valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) que havia na conta, bem como do limite, cujo valor corresponde a R\$ 200,00 (duzentos reais). Destaca que os empréstimos, realizados sem contrato, não obtiveram a anuência da autora. Postula pela concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de efetivar descontos em sua conta bancária ou em seu benefício previdenciário relativos aos empréstimos combatidos, bem como de realizar novos empréstimos sem sua anuência, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais). Requer a aplicação do instituto da inversão do ônus com a apresentação das filmagens da agência realizadas no dia 29/09/2021, no período das transações fraudulentas. Ao final, pugna pela procedência da ação para declaração de inexistência do débito, anulação dos empréstimos, condenação ao pagamento do valor de R\$ 1.054,44 (mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária, para recomposição dos prejuízos patrimoniais, além das parcelas futuras, diante da responsabilidade objetiva do Banco. Postula, também, pela indenização pelos danos morais suportados, em valor não inferior a R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Com a inicial, documentos (fls. 20/43).

Deferido o pedido de tutela de urgência através de decisão de fl. 45.

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 50/93, com documentos). Como matéria preliminar, sustenta ilegitimidade passiva, considerando-se que apenas intermediou a contratação dos seguros, na condição de mero estipulante dos contratos de seguro, garantidos pela empresa Zurich Minas Brasil Seguros, única legitimada a responder pelos riscos previstos na apólice dos seguros realizados. Argumenta que o estipulante é mandatário legal do grupo segurado, representando-o perante a seguradora. No mérito, refuta os fatos narrados. Discorre que a autora não se dirigiu até a agência bancária para informar o ocorrido e que as supostas meliantes agiram à revelia da autora, que deixou cartão e senha com pessoas completamente desconhecidas. Argumenta inexistir comprovação, por meio de protocolo ou de singela senha, de comparecimento ao Banco com o objetivo de realizar o bloqueio de seus cartões. Saliencia que o fato delituoso ocorreu pela manhã, tendo a autora tempo suficiente para dirigir-se até a agência ou ligar ao Banco para cancelar seu cartão. Que à título de um prêmio a autora confiou em terceiros e, posteriormente, teve a bolsa supostamente subtraída. Obtempera o fato de a autora em momento algum mencionar ser sua senha pessoal e intransferível. Afirma o Banco já ter adimplido sua parte na relação contratual, pelos depósitos efetivados, já sacados, pela utilização de cartão e senha, motivo pelo qual os descontos inserem-se no exercício regular da instituição de recebimento pela transferência dos valores. Frisa que na modalidade dos empréstimos realizados, com assinatura eletrônica, por meio de cartão e senha, os meios utilizados para comprovar a concretização das operações realizadas divergem dos utilizados em operações convencionais, em que o contrato é impresso e é aposta a assinatura do contratante. Informa que é fornecido ao cliente segunda via da contratação, na qual constam os dados da operação realizada no caixa de autoatendimento, digitados pelo contratante no caixa eletrônico. Os empréstimos

foram realizados em terminal de autoatendimento por meio de cartão e senha, cuja guarda e conservação é de inteira responsabilidade da parte. Salienta que da análise dos extratos da conta da autora é possível constatar que os valores de todos os empréstimos foram sacados no mesmo dia de sua contratação. Aduz haver culpa exclusiva da autora, por falta de comunicação imediata do furto sofrido ao Banco e por falta de diligência ao manter conjuntamente seu cartão e senha pessoal (artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Defende não ser caso de aplicação de inversão do ônus da prova e destaca que o Boletim de Ocorrência apresentado se trata de mera prova unilateral, sem parte no conjunto probatório dos fatos. Aduz não haver configuração de ato ilícito cometido pelo Banco e, por conseguinte, direito à indenização por danos morais. Postula pela improcedência da ação e, na hipótese de reconhecimento de fraude, seja a parte autora condenada a restituir a importância que lhe foi disponibilizada.

Houve réplica.

Às fls. 125/129 sobreveio ofício do INSS, informando a não localização dos descontos relativos aos contratos de empréstimos de números 25109, 25110 e 25111 no benefício de titularidade da autora.

Instadas a especificarem provas, a autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 134/135) e o réu informou não haver mais provas a produzir (fls. 136/139).

Às fls. 140/142 a autora informa o descumprimento da liminar e o creditamento de dois valores realizados em sua conta com a descrição "estorno do débito de empréstimo", em 28/05/2022.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço diretamente a lide, em julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, máxime se considerarmos que as partes declinaram da produção de outras provas.

A preliminar arguida não comporta acolhimento.

Os documentos de fls. 24/26 e 29 demonstram a relação existente entre as partes, o que denota a legitimidade do réu para constar do polo passivo desta ação.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

De início, reconheço a responsabilidade objetiva do réu, fundada na teoria do risco do negócio, que somente será excluída nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º cc artigo 17, todos da Lei n. 8.078/90).

A teoria do risco do negócio, conforme ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves "funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que auferir os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8ª Edição, 2003, p. 339).

Pois bem.

Pretende a autora a declaração de inexigibilidade das transações financeiras

efetivadas em sua conta bancária, sob o fundamento de fraude e indevida utilização de seus dados cadastrais, além de uma indenização pelos danos morais suportados.

Não se olvida que todo cliente tem o dever de resguardar seu cartão, senha pessoal e demais documentos.

Contudo, é do Banco o ônus de provar o descumprimento de tal dever.

Cabia ao Banco garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes à distância. A realização de diversas contratações em sequência, envolvendo valores, destoante do perfil financeiro do cliente e em curtíssimo espaço de tempo, evidencia a fraude que deveria ter sido constatada pelos sistemas do Banco-réu, estando ao seu alcance a verificação individualizada das transações.

No mais, a fraude praticada por terceiros não elide a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária".

Assim, demonstrado que o dano decorreu de fortuito interno da própria atividade do Banco, de rigor o cancelamento dos contratos de origem fraudulenta e a devolução dos valores eventualmente descontados da conta bancária da autora, vinculados aos contratos anulados.

Por outro lado e considerando que a autora também contribui para o prejuízo financeiro, agindo com negligência ao facilitar que seus dados bancários fossem utilizados por terceiros, haja vista que imprescindível o conhecimento da senha para conclusão das operações realizadas, embora não sendo este o fato determinante da fraude, bem como, considerando que os fatos descritos na inicial não se tornaram públicos, não ofendendo a honra da autora, sem qualquer lançamento de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito, entendo que não há dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente no cancelamento dos contratos de empréstimo de números 000804460112 (25109), 910001132724 (25111) e 910001132721 (25110), confirmando-se a liminar concedida à fl. 45, bem como na devolução dos valores eventualmente descontados da conta bancária da autora em relação a estes contratos, desde que devidamente comprovado o desconto. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios no valor correspondente a 20% do valor dos contratos cancelados, sendo devido um terço pela parte autora e devidos dois terços pelo réu, observada eventual gratuidade concedida.

Publique-se e intime-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Americana, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA